

EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 30-10-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processos: TC-017581.989.24-1
TC-017674.989.24-9.

Representantes: Dalcin & Custódio Advogados
Felipe Marquezelli Chagas.

Representada: Prefeitura Municipal de Barrinha.

Assunto: Exame prévio do edital retificado da Concorrência Pública nº 01/2024, do tipo melhor técnica e preço, que tem por objeto a *“outorga da concessão para prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município”*.

Responsável: José Marcos Martins (Prefeito).

Advogados cadastrados no e-TCESP: Tatiane Cristina Custodio (OAB/SP nº 383.392), Felipe Marquezelli Chagas (OAB/SP nº 393.663) e Antonio Sergio de Araujo Junior (OAB/SP nº 391.229).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CONCORRÊNCIA. CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. GARANTIA DE PROPOSTA EM PRAZO SUPERIOR AO DA VIGÊNCIA DA OFERTA. INDEVIDA LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO. PRECARIEDADE DO EVTE. OMISSÃO QUANTO AOS VALORES DAS APÓLICES. ERRÔNEA ESTIMATIVA DO VALOR DE OUTORGA. SUPERESTIMATIVA DA RECEITA DA CONCESSÃO. IMPRECISÃO SOBRE O MÉTODO ADOTADO PARA CALCULAR OS VALORES DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS MEIOS DE OBTENÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS INVESTIMENTOS. BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA PARA A PROVA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO E GARANTIA DE PROPOSTA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame prévio de edital** retificado da Concorrência Pública nº 01/2024, do tipo melhor técnica e preço, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA**, cujo objeto é a *“outorga da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário na área de concessão, em caráter de exclusividade no Município, pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, abrangendo ainda serviços de projeto, licenças ambientais, construção, melhoramentos, ampliação, revisão, operação e manutenção das unidades integrantes dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais de produção e distribuição de água potável, coleta, afastamento, tratamento e disposição de esgotos sanitários, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o atendimento aos usuários, bem como a prestação de serviços complementares”*.

1.2 Insurgiu-se **DALCIN & CUSTÓDIO ADVOGADOS** contra os seguintes aspectos do ato convocatório:

- a) concessão de serviços que *“não atinge na totalidade as metas previstas na legislação federal, por não abranger a área rural”*;
- b) indicação de atividade (operação e manutenção do sistema de gestão comercial) sem relevância financeira para a prova de capacidade operacional e profissional das licitantes¹;

¹ 23.21.2 Comprovação de habilitação técnico-operacional
(...)

23.21.2.2.3 Experiência da licitante em operação e manutenção do sistema de gestão comercial, incluindo as atividades de leitura de hidrômetro, faturamento, cobrança e atendimento ao público em sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que atenda, no mínimo, 15.868 (quinze mil, oitocentos e sessenta e oito) habitantes.

(...)

23.21.3 Comprovação de habilitação técnico-profissional:

23.21.3.1 Comprovação de vínculo com profissional devidamente registrado no CREA, que comprove experiência como Responsável Técnico, na prestação dos serviços indicados nos subitens 23.21.2.2.1; 23.21.2.2.2; 23.21.2.2.3 (parcelas de maior relevância), por meio de certidão ou atestado emitido pelo CREA, sem a imposição de quantitativos mínimos ou prazos máximos.

c) exorbitante valor (R\$ 34.193.992,40)² requisitado para experiência na captação de recursos financeiros, mediante financiamento ou operação financeira estruturada;

d) exigência de garantia da proposta com vigência superior (mínimo de um ano)³ ao de sua própria validade (cento e oitenta dias);

e) deficiência no projeto, pois deixa de prever a estimativa de crescimento da demanda da produção de água ou mesmo da “reservação”, assim como dos investimentos necessários para supri-la;

f) fragilidade do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, citando as seguintes falhas:

f.1) errônea estimativa no valor de investimento, pois o EVTE utilizou o valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões) em seus estudos, enquanto o *“edital fixa o valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões), além desse valor ter sido ratificado em esclarecimento pela Prefeitura de Barrinha”*;

f.2) superestimada previsão de reajuste da tarifa, que se mostra *“49% superior a praticada hoje pela Prefeitura”*;

f.3) omissão quanto os cálculos de amortização e depreciação;

f.4) falta de indicação dos valores de seguro e garantias.

1.3 Por sua vez, **FELIPE MARQUEZELLI CHAGAS** acrescentou as seguintes censuras ao instrumento convocatório:

g) ausência de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira, pois constatou a *“existência de um único documento destinado a trazer as diretrizes para a elaboração das propostas”*, no qual *“não há transparência sobre como tais valores foram obtidos”*, tampouco *“identificação precisa do fluxo financeiro*

² 23.21.2.5 Comprovação de que a LICITANTE participou da captação de recursos financeiros mediante financiamento ou operação financeira estruturada no valor de, ao menos R\$ 34.193.992,40 (Trinta e quatro milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

³ 17- GARANTIA DE PROPOSTA

17.1 A LICITANTE deverá prestar GARANTIA DE PROPOSTA em favor do MUNICÍPIO no valor de R\$ 7.718.808,96 (sete milhões, setecentos e dezoito mil, oitocentos e oito reais e noventa e seis centavos), correspondente ao percentual de 1% (um por cento) sobre o VALOR ESTIMADO DO CONTRATO.
(...)

17.6 A GARANTIA DE PROPOSTA deverá ter vigência mínima de 1 (um) ano a contar da data da SESSÃO DE ABERTURA DO CERTAME.

para o período de operação previsto no contrato, bem como os riscos associados aos investimentos”;

h) existência de parâmetros distintos para o cálculo do capital social⁴ (valor do investimento estimado), da garantia da proposta⁵, do patrimônio líquido⁶ (valor estimado do contrato) e da garantia de execução (valor total estimado para os investimentos nos 05 primeiros anos do Contrato de Concessão), afora desatenderem ao entendimento desta Corte, no sentido de que devem ser considerados apenas os *“investimentos a serem efetuados nos primeiros 12 meses de contratação, tudo para estímulo à competitividade”*;

i) injustificada limitação ao somatório de atestados de capacidade técnica⁷; e

j) fixação de número máximo de empresas consorciadas⁸ sem a devida justificativa técnica.

1.4 Os autos foram distribuídos por prevenção, em virtude da conexão com a matéria tratada no TC-015339.989.24-6, que abrigou representação formulada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, cujo pleito de liminar suspensão do certame foi indeferido liminarmente.

⁴ 25.2.2 O capital social integralizado mínimo da SPE será correspondente a 10% (dez por cento) do valor dos INVESTIMENTOS previstos no PLANO DE NEGÓCIOS, devidamente subscrito em moeda corrente nacional. Previamente à assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, deverá ser integralizado no mínimo o equivalente a 5% (cinco por cento) do capital social.

⁵ 17- GARANTIA DE PROPOSTA

17.1 A LICITANTE deverá prestar GARANTIA DE PROPOSTA em favor do MUNICÍPIO no valor de R\$ 7.718.808,96 (sete milhões, setecentos e dezoito mil, oitocentos e oito reais e noventa e seis centavos), correspondente ao percentual de 1% (um por cento) sobre o VALOR ESTIMADO DO CONTRATO.

⁶ 23.22.10 Patrimônio líquido de no mínimo R\$ 77.188.089,60 (setenta e sete milhões, cento e oitenta e oito mil, oitenta e nove reais e sessenta centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO, cuja comprovação será feita através do Balanço Patrimonial, ou outro documento idôneo e aceito nos termos da legislação correlata

⁷ 23.21.2.4 Para atendimento dos quantitativos mínimos estabelecidos nos subitens 23.21.2.2.1; 23.21.2.2.2; 23.21.2.2.3 (parcelas de maior relevância); é permitido somatório de até 3 atestados.

⁸ 13.4 Caso a LICITANTE participe desta LICITAÇÃO por meio de CONSÓRCIO, deverá observar as seguintes regras, sem prejuízo de outras existentes no EDITAL: (...)

c) O CONSÓRCIO deverá ser constituído por no máximo 3 (três) empresas consorciadas;

1.5 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

1.6 Notificada, a **Representada** refutou a alegada inexistência de Estudos de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira (EVTE), afirmando estarem dispostos no Anexo 4, tendo sido elaborados conforme as premissas constantes no Plano Municipal de Saneamento Básico, integrando-o.

Acrescentou serem meros estudos referenciais, servindo “*apenas e tão somente para demonstrar a viabilidade da delegação*”, não eximindo os licitantes de fazerem suas próprias avaliações. A seu ver, cabe à concessionária, “*consoante as diretrizes mínimas e mandatórias estipuladas no instrumento contratual*”, adotar a melhor forma de implantar a infraestrutura contratada e prestar os serviços concedidos.

No que tange às apontadas inconsistências nos estudos de viabilidade técnica, notadamente em relação ao crescimento de demanda e valores de outorga, reiterou a natureza referencial dos estudos. Assim, aduziu que, de acordo com a matriz de risco, incumbe à concessionária assumir a variação da demanda, que pode ser de até 10 % a mais ou menos do previsto no Plano Municipal de Água e Esgotamento 2024.

Neste contexto, afirmou que a concessionária deve realizar todos os investimentos necessários para atender ao risco de demanda que lhe foi alocado.

Por sua vez, alegou que a diferença de R\$ 1.000.000,00 no valor da outorga pode ser considerada irrelevante no contexto de um contrato de 35 anos.

Aludiu que o reajuste anual automático das tarifas já decorre do novo marco legal do saneamento básico, ocorrendo independente de aprovação em lei específica, como erroneamente suscitado na inicial. Acrescentou ao tema que a Cláusula Décima Terceira do Contrato de Concessão prevê expressamente a sistemática de reajuste a ser aplicada.

Quanto à suscitada imprecisão sobre os cálculos de amortização e depreciação, esclareceu que as licitantes devem observar as normas contábeis aplicáveis ao caso, incluindo a Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) e o Pronunciamento Técnico CPC 04, que orientam sobre a forma de contabilização de concessões de serviços públicos e a amortização de ativos intangíveis.

Aduziu que os custos com seguros e garantias estão alocados nas "outras despesas", devendo os licitantes fazerem suas próprias avaliações sobre tais valores.

Atinente às metas de universalização e tratamento de esgoto, defendeu que a concessão prevê a manutenção de 100% de cobertura na área urbana e que a universalização na área rural será alcançada até 2033, com medidas cabíveis sendo adotadas para atender plenamente as metas impostas.

Esclareceu que, atualmente, o Município não possui tratamento de esgoto, estando previstos, nos primeiros 4 anos da concessão, investimentos significativos, com a implementação ao final desse ciclo.

A seu ver, as exigências de capital social mínimo, patrimônio líquido e garantias com base no total dos investimentos ao longo da concessão estariam em conformidade com as diretrizes jurisprudenciais adotadas por esta Corte, conforme exemplificam o TC-10075.989.16-0⁹ e Súmula nº 43.

Sustentou que a exigência de garantia de proposta, com validade mínima de um ano, é necessária para cobrir possíveis descumprimentos de obrigações decorrentes de lei ou do edital, mesmo após o prazo de validade da proposta comercial.

Concernente à qualificação técnica, ressaltou a relevância de requerer experiência em gestão comercial, porquanto visa garantir a eficiência e sustentabilidade financeira da operação, além de proporcionar um serviço de qualidade aos usuários.

Aduziu que a prova de captação de recursos financeiros, no valor de R\$ 34.193.992,40, *"corresponde a 50% dos investimentos totais previstos*

⁹ Sessão Plenária de 29-06-2016, relator Conselheiro-Substituto Alexandre Manir Figueiredo Sarquis

para o presente projeto”, conforme autoriza a Lei nº 14.133/21, servindo para demonstrar a capacidade da licitante para realizar os investimentos necessários.

Afiçou inexistir censura ao somatório máximo de três atestados, pois “busca trazer um mínimo de segurança à contratação”, sendo que, “na prática, em cada um desses atestados deverá os licitantes comprovarem que já prestaram, aproximadamente 20% dos quantitativos exigidos no edital” .

Por fim, recordou que o art. 15, § 4º, da Lei nº 14.133/21, admite que o estabelecimento de limite máximo para o número de empresas consorciadas. Situação que, no seu entender, “contribui para ampliar a concorrência no certame, e evitar uma paradoxal cartelização”.

1.7 O Setor de Engenharia da Assessoria Técnico-Jurídica, nos aspectos afetos a sua área de atuação, manifestou-se pela procedência parcial das impugnações.

De plano, destacou que “as metas descritas no edital são compatíveis com os dados do cenário atual e com o que se pretende executar ao longo da concessão no que se refere a água e esgotamento no Município”, que “não prevê cobertura à área rural”.

Ademais, sopesou que, “mesmo considerando apenas a área urbana, já foi alcançada uma cobertura de 100% para abastecimento de água e coleta de esgoto, índices que atendem às metas estabelecidas pela Lei nº 11.445/2006 e que devem ser mantidos ao longo de toda a concessão. E esses índices estão refletidos nas metas definidas no Termo de Referência”.

Constatou, ainda, que o Termo de Referência prevê grandes investimentos nos primeiros quatro anos da concessão, de modo a não caber censura ao estabelecimento da meta de implementação efetiva do tratamento de esgoto apenas ao final desse ciclo.

A seu ver, insubsistentes as queixas aos termos da qualificação técnica, porquanto os serviços de gestão comercial no OPEX (despesas operacionais) e CAPEX (despesas de capital) possuem relevância técnica dentro do contrato, pois “são atividades essenciais para o atendimento ao público e

comuns em contratos que envolvam a concessão de abastecimento de água e esgotamento sanitário". Por sua vez, a regra do somatório máximo de 03 atestados garante a operacionalidade e a capacidade na condução dos serviços.

Ponderou não subsistir a ausência de estimativa de crescimento da demanda da produção de água ou da capacidade de reservação, pois o edital esclarece que *"não serão necessárias adequações futuras devido ao crescimento populacional ao longo dos 35 anos de concessão"*, pois a demanda permanecerá estável.

Contudo, avaliou indispensável realizar o controle de perdas na rede de distribuição, que atualmente apresenta um índice elevado.

Quanto à diferença de R\$ 1.000.000,00 entre o valor de outorga apresentado no estudo de viabilidade e o disposto no edital, recomendou sejam eles alinhados, para assegurar que *"as decisões tomadas durante o processo sejam fundamentadas, coerentes e alinhadas aos objetivos públicos"*.

Sopesou proceder parcialmente a suscitada carência dos Estudos de Viabilidade Técnica, pois *"o edital inclui o Anexo 4, que apresenta o EVTE e menciona os valores orçados para investimentos e OPEX, mas não oferece transparência sobre como esses valores foram determinados"*.

1.8 Seu congênere em **Economia** destacou que o valor solicitado na prova de captação de recursos financeiros (R\$ 34.193.992,40) corresponde a 50% do montante de investimentos estimados (R\$ 68.387.984,71), dentro do limite legal para este fim.

Ademais, por se tratar de concessão por 35 anos, entendeu pertinente limitar que a comprovação se dê, em parte, mediante único atestado, notadamente porque a demonstração incidirá sobre, no mínimo, a metade do valor exigido, que corresponde a R\$ 17.096.966,20.

Acrescentou que a pretensão da Representante de se admitir vários atestados com montantes irrisórios, ainda que atinjam a soma exigida, não serviria para comprovar a capacidade almejada.

Ressaltou que este entendimento também foi adotado nos autos dos TC-023256.989.19-5¹⁰ e TC-021167.989.23-5¹¹, entre outros.

Sopesou ser infundada a afirmação de que o reajuste tarifário dependeria de aprovação pelo legislativo municipal, porquanto as disposições das Leis nºs 14.133/21 (art.92, V)¹², 8.987/95 (art. 23, IV)¹³ e 11.445/07 (art. 11, § 2º, IV, b)¹⁴ estabelecem que os critérios para sua ocorrência devem ser fixados no contrato. No caso, observou que os critérios e parâmetros para aplicação do reajuste tarifário constam expressamente da Cláusula Décima Terceira (itens 13.1 a 13.10) da Minuta do Contrato de Concessão.

Por outro lado, avaliou proceder parcialmente as apontadas precariedades do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica contido no Anexo 4, que deixou de indicar as *“bases de dados que deram origem ao levantamento do Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) e do Demonstrativo de Fluxo de Caixa do Projeto (DFC)”*.

Destacou, neste sentido, a falta de *“histogramas de consumo, segregados por localidades, categorias e faixas de consumo, número de ligações, economias, volumes medidos e faturados, assim como do valor do faturamento médio de período antecedente, para servir de subsídio à avaliação da realidade das metas planejadas e da exequibilidade da concessão com base nos valores lançados no EVTEF”*.

Ressaltou a importância destes elementos para o cálculo da receita, pois *“é utilizada a Tarifa Média de Água (TMA) de R\$ 4,46, que representa um aumento total de 49% em relação a tarifa média de R\$ 3,00 praticada*

¹⁰ Sessão Plenária de 05-02-2020, Relatora Conselheira Cristiana de Castro Moraes

¹¹ Sessão Plenária de 29-11-2023, Relator Conselheiro Robson Marinho

¹² Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: [...] V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

¹³ Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: [...] IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas;

¹⁴ Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico: [...] § 2º Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de programa, as normas previstas no inciso III do caput deste artigo deverão prever: [...] IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo: [...] b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;

atualmente pelo município”, sem a exposição da memória de cálculo que chegou a este último valor.

Anotou não ter nenhuma serventia o fornecimento isolado da “Tarifa Média de Água (TMA)” e “Tarifa Média de Esgoto (TME)”, sem a divulgação dos “histogramas de consumo para a realização de projeções e, por conseguinte, para a apuração das receitas estimativas de arrecadação tarifária”.

Recordou que as empresas também necessitam de “informações e dados atuais/históricos, pelo menos dos 12 últimos meses, e a descrição precisa dos equipamentos (estações de tratamento, estações elevatórias de esgoto, poços e adutoras) existentes e as condições em que se encontram, para a compreensão da extensão e dos riscos envolvidos no negócio”.

Entendeu que tais omissões impossibilitam estabelecer a correlação entre o Termo de Referência (Anexo III) e o Anexo IV – contendo o Plano Municipal de Saneamento e “Estudo de Viabilidade/Procedimento de Manifestação de Interesse”.

Observou que “os quadros relativos à OPEX e aos investimentos estão detalhados no nível de orçamento sintético, (...) com o levantamento dos serviços e investimentos a serem executados de forma agregada, com valores anuais”, porém, sem a indicação da metodologia empregada para aferição dos valores, conforme preceitua o § 4º do art. 10¹⁵ da Lei Federal nº 11.079/04. Assim, entendeu proceder parcialmente a suscitada falha, carecendo de transparência sobre como foram obtidos os valores relativos aos investimentos (CAPEX) programados para o período da concessão.

Aduziu que, igual ao representante, não conseguiu localizar, no edital e anexos, informações de quais foram os dados que embasaram o cálculo dos valores anuais de depreciação e amortização ao longo do período da concessão, prosperando a queixa nesse aspecto.

¹⁵ O Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: (...) § 4º Os estudos de engenharia para a definição do valor do investimento da PPP deverão ter nível de detalhamento de anteprojeto, **e o valor dos investimentos para definição do preço de referência para a licitação** será calculado com base em valores de mercado considerando o custo global de obras semelhantes no Brasil ou no exterior ou **com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento sintético**, elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica. (grifei)

De igual modo, sublinhou a importância de que o ato convocatório também passe a indicar os valores mínimos das coberturas de sinistros, o que permite o correto levantamento dos custos pelos participantes do certame.

Avaliou proceder parcialmente a censura à base de cálculo adotada para a prova de capital social mínimo e da garantia de execução requisitada, pois o parâmetro correto é o valor previsto para os investimentos necessários à execução do contrato, e não os investimentos a serem efetuados nos primeiros 12 meses da contratação, como requer o peticionário.

1.9 Sob a ótica da **Unidade Jurídica**, procede a queixa ao prazo de vigência da garantia de proposta (1 ano a contar da data da sessão de abertura do certame), pois *“impede a liberação dos compromissos assumidos pelas licitantes, tão logo decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para assinatura do contrato”* (Art. 90, § 3º, da Lei nº 14.133/21).

Neste ponto, sublinhou que o artigo 58 da NLLC impõe que, encerrada a licitação, tal garantia seja *“liberada a todas as proponentes em até 10 (dez) dias úteis da data de assinatura do contrato ou da declaração do certame como fracassado, salvo se presente causa que autorize sua execução (§3º)”*.

Outrossim, ressaltou que a aludida garantia não se confunde com a de execução do objeto, necessária ao *“fiel cumprimento das obrigações contratuais por parte da concessionária”* (evento 49.3, fl. 06).

Recordou que a Lei nº 14.133/21 estabelece, como regra geral, a admissão de consórcios e a ausência de limites ao número de seus integrantes, exigindo justificativas técnicas robustas para qualquer cláusula em sentido contrário.

1.10 A **Chefia da ATJ** divergiu apenas quanto ao valor da tarifa média (R\$ 4,46) considerada no EVTE, que se mostra 49% superior à atualmente praticada no Município (R\$ 3.00), sem a devida demonstração da memória de cálculo utilizada para lastreá-la.

Ressaltou que a tarifa média é elemento central na projeção de receitas e nas balizas econômico-financeiras da concessão.

No mais, endossou os pareceres das suas áreas técnicas especializadas.

1.11 As conclusões do **Ministério Público de Contas** não destoaram das de sua preopinante.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA** pretende a “*outorga da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário na área de concessão, em caráter de exclusividade no Município, pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos*”.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação de regência e à jurisprudência desta Corte.

2.2 De início, considerando o caráter eminentemente técnico das insurgências, acolho os percucientes pareceres da Assessoria Técnico-Jurídica.

Assim, com o Setor de Engenharia, entendo não prosperar o alegado descumprimento das metas estabelecidas pelo novo marco legal do saneamento, quando o estudo é expandido para áreas urbanas e rurais.

Neste ponto, foi destacado que o Termo de Referência “*específica que a área de abrangência do projeto corresponde ao perímetro urbano do Município; sem incluir a área rural*”, pois o Plano Municipal de Água e Esgoto não faz qualquer menção à cobertura da área rural na concessão.

Ainda nesse aspecto, foi ressaltado que o Município já atingiu 100% de cobertura de abastecimento de água e coleta de esgoto na área urbana, de modo a indicar que houve o cumprimento das metas estabelecidas pelo novo marco legal, porquanto a população rural representa apenas 1% do total populacional.

Por outro lado, mesmo que a concessão não abrangesse a área rural, noto que a Municipalidade se comprometeu a adotar medidas para assegurar o abastecimento de água da população rural até 2033, por outros modos de fornecimento e/ou contratos distintos.

Ademais, com aquela Assessoria, avalio não subsistir o aventado retrocesso na cobertura do tratamento de esgoto, pois o *“Termo de Referência estabelece uma meta de 0% nos primeiros quatro anos da concessão, com a previsão de atingir 100% apenas a partir do quinto ano”*.

Desta forma, apesar de, atualmente, não haver *“tratamento de esgoto sanitário no Município (...) estão previstos grandes investimentos nos primeiros anos da concessão, com a implementação efetiva do tratamento de esgoto apenas ao final desse ciclo, conforme indicado nas metas estabelecidas na Tabela 7, do item 5.3.2, do Termo de Referência”* (grifei).

Diante do exposto, nota-se que o certame cumpre as metas de universalização do saneamento para a área urbana, tendo planos para estendê-las à área rural até 2033, sendo que as metas de tratamento de esgoto serão atingidas gradualmente, com investimentos significativos nos primeiros anos da concessão

2.3 Também na esteira de sua manifestação, pondero ser insubsistente a crítica à exigência de *expertise* em serviços de gestão comercial em OPEX e CAPEX, pois *“são atividades essenciais para o atendimento ao público e comuns em contratos que envolvam a concessão de abastecimento de água e esgotamento sanitário”*, evidenciando, assim sua relevância técnica para o ajuste.

A seu turno, a população indicada (15.868 habitantes) *“atende ao limite de 50% do objeto, definido no § 2º do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21”*.

2.4 Outrossim, com a vertente Econômica, avalio não caber censura ao valor (R\$ 34.193.992,40) requisitado na experiência em captação de recursos financeiros, porquanto *“corresponde a 50% do montante de investimentos estimados (R\$ 68.387.984,71), tal como autoriza o art. 67, §2º, da Lei 14.133/21”*.

Tampouco prospera a queixa à imposição de que a prova se dê, em parte, por meio de um único atestado, pois *“os elevados investimentos exigidos pela concessão indubitavelmente tornam a comprovação da exigência da experiência anterior na captação de recursos de terceiros indispensável à aferição da qualificação das proponentes”*.

Ainda com a Assessoria, afasto a crítica ao condicionamento de que o atestado *“tenha, no mínimo, 50% (R\$ 17.096.966,20) do montante exigido no subitem 23.21.2.5.2 (R\$ 34.193.992,40) para comprovação de experiência anterior em captação de recursos financeiros (‘Project Finance’)”*.

Tal exigência protege a Administração da *“apresentação de inúmeros atestados com montantes irrisórios que, embora atinjam a soma exigida no edital, não são suficientes a demonstrar, inequivocamente, a capacidade técnica almejada, principalmente em se tratando de contratação de grande vulto, como o caso”*.

Nesse sentido, aliás, foram as decisões proferidas por este Plenário nos autos dos processos TC-000612.989.24-4¹⁶ e TC-021167.989.23-4, entre outros¹⁷.

2.5 Aplico igual raciocínio à limitação ao somatório de três atestados de capacidade técnica, eis que, ao consideramos *“que foi exigido 50% do objeto,*

¹⁶ Sessão Plenária de 20-03-2024, sob minha relatoria

¹⁷ Sessão Plenária de 29-11-2023, relator Conselheiro Robson Marinho

cada atestado apresentaria, em média, uma quantidade equivalente a 17% do objeto, o que corresponde a serviços realizados em um município de cerca de 5.300 habitantes”, como pontuou o Setor de Engenharia.

Nesta medida, ante o silêncio da Lei nº 14.133/21 sobre o tema, avalio que a regra não destoa da razoabilidade, nem restringe a competição, servindo apenas para assegurar a operacionalidade e a capacidade da licitante na condução dos serviços.

2.6 Não prospera a suscitada carência de estimativa de crescimento da demanda da produção de água ou da capacidade de reservação, porquanto o edital deixa claro que, ao longo dos 35 anos de concessão, *“não haverá investimentos voltados ao aumento da produção de água ou da capacidade de reservação, já que a demanda permanecerá estável”*.

Inobstante, mostra-se indispensável a realização do *“controle de perdas na rede de distribuição, que atualmente apresenta um índice elevado, o que aumentará a disponibilidade de água no município”*.

2.7 Insubsistente, ainda, a tese de que o reajuste tarifário dependeria de aprovação do legislativo municipal, porquanto as Leis nºs 14.133/21, 8.987/95 e 11.445/07¹⁸ dispõem que os critérios de sua aplicação devem ser fixados pelo contrato, constando expressamente na Minuta Contratual.

2.8 Mesma sorte, contudo, não guarda a inadequada fixação de vigência da garantia de proposta (mínimo de um ano), superior à validade da própria oferta (180 dias), na medida em que impede liberar as licitantes dos compromissos assumidos, quando do término da validade de suas propostas, mesmo não tendo sido convocadas para assinatura do contrato (Art. 90, § 3º, da Lei nº 14.133/21).

Conforme consignei na medida liminar, o referido prazo, afora destoar da finalidade a que se destina (evidenciar a seriedade da oferta e assegurar à Administração de eventuais prejuízos, caso não ocorra a assinatura do contrato por desídia da

¹⁸ Vide notas 12, 13 e 14

vencedora), exorbita do disposto no artigo 58 e parágrafos da NLLC, que impõe que ela seja *“devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação”* (§ 2º), salvo se presente causa que autorize sua execução (§3º).

Outrossim, ressalto que a aludida garantia não se confunde com a de execução do objeto, dirigida exclusivamente à licitante vencedora na fase de assinatura do contrato, *“a fim de resguardar a Administração quanto ao fiel cumprimento das obrigações contratuais por parte da concessionária”*.

2.9 Afora isso, relembro que o art. 15, *caput* e § 4º, da Lei nº 14.133/21, trouxe novas regras para a participação de consórcios, de modo que qualquer vedação ou limitação ao número de sua composição deve ser devidamente justificada, com base em critérios técnicos.

Deste modo, necessário que a Municipalidade adéque o edital às disposições da norma, permitindo a participação de consórcios sem limitação ao número de empresas consorciadas ou que, caso entenda ser ela imprescindível, justifique-a tecnicamente no edital.

2.10 Também prospera a apontada precariedade do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeiro contido no Anexo 4, que não informa as *“bases de dados que deram origem ao levantamento do Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) e do Demonstrativo de Fluxo de Caixa do Projeto (DFC).”*

Além disso, a instrução constatou que o EVTE também carece da disponibilização de informações essenciais ao plano de negócios, como os histogramas de consumo, número de ligações, economias, volumes medidos e faturados, valor do faturamento médio de período antecedente, memória de cálculo para obtenção do valor referente à tarifa de água, entre outros.

Aliás, os aludidos elementos se mostram relevantes para o cálculo da receita, que utiliza Tarifa Média de Água (TMA) 49% superior à praticada atualmente pelo município, conforme se verifica no próximo tópico.

Como se não bastasse, as empresas também necessitam de *“informações e dados atuais/históricos, pelo menos dos 12 últimos meses, e a descrição precisa dos equipamentos (estações de tratamento, estações elevatórias de esgoto, poços e adutoras) existentes e as condições em que se encontram, para a compreensão da extensão e dos riscos envolvidos no negócio”*.

Ademais, a própria Municipalidade reconheceu existir a apontada diferença de R\$ 1.000.000,00 entre o valor apresentado no estudo de viabilidade (R\$ 5 milhões) e o disposto na cláusula 9.1.19 da Minuta do Contrato (R\$ 6 milhões).

Portanto, com o Setor de Economia, entendo que tais omissões e imperfeições impedem *“estabelecer a correlação entre o Termo de Referência (Anexo III) e o Anexo IV – contendo o Plano Municipal de Saneamento e “Estudo de Viabilidade/Procedimento de Manifestação de Interesse”, prejudicando a elaboração do plano de negócios e a apresentação da proposta comercial.*

2.11 Soma-se a estas falhas, a existência de uma possível superestimativa da receita da concessão, eis que o valor da tarifa média de água (R\$ 4,46), adotado como parâmetro no EVTE, revela-se 49% superior ao que é praticado atualmente no Município (R\$ 3,00).

Como pontuou a Chefia da ATJ, *“a despeito dos reajustes a que a concessionária terá direito durante a vigência contratual, não restou objetivamente demonstrado no EVTE a memória de cálculo utilizada para lastrear a tarifa média atualmente praticada de R\$ 3,00, e por via reflexa, aquela considerada nas projeções futuras, de R\$ 4,46, cujo valor é elemento central na projeção de receitas e um dos pilares de sustentação das balizas econômico-financeiras da concessão”*.

2.12 Procede, igualmente, a suscitada carência de informações, no edital e anexos, sobre os dados que embasaram o cálculo dos valores anuais de depreciação e amortização ao longo do período da concessão, indicados no Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE e no Demonstrativo de Fluxo de Caixa do Projeto – DFC.

Neste ponto, inobstante a Prefeitura sustente o dever das licitantes de observar as normas aplicáveis, incluindo a Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão e o Pronunciamento Técnico CPC 04, deixa de esclarecer a forma de estabelecimento dos valores indicados para a depreciação e amortização dos bens.

Deste modo, necessário que o ato convocatório passe a especificar o método adotado para o cálculo da depreciação e amortização, descrevendo os critérios e parâmetros considerados para obtenção dos valores demonstrados no fluxo de caixa.

2.13 Avalio, com a Unidade de Economia, que a falta de *“delimitação dos valores das apólices de seguro tem o condão de impactar diretamente na formulação das propostas, razão pela qual deve o instrumento convocatório indicar os valores mínimos de coberturas de sinistros, de modo a viabilizar o correto levantamento dos custos pelos participantes do certame”*.

2.14 Por sua vez, com o MPC, acolho em parte os termos da insurgência aos parâmetros utilizados para a demonstração do patrimônio líquido mínimo e da garantia de proposta, que remetem ao valor estimado do contrato, pois a *“adequada base de cálculo a ser utilizada para tais requisitos deve ser o valor previsto para os investimentos necessários à execução do contrato, e não os investimentos a serem efetuados nos primeiros 12 meses da contratação, como requer o peticionário”*.

2.15 De igual modo, avalio proceder parcialmente a suscitada falta de transparência sobre como foram obtidos os valores relativos aos investimentos.

Isto porque, em que pese os quadros relativos aos investimentos estarem detalhados no nível de orçamento sintético - *com o levantamento dos serviços e investimentos a serem executados de forma agregada, com valores anuais* -, deixou de

atender parte do disposto no § 4º do art. 10 da Lei Federal nº 11.079/04¹⁹, ao omitir a metodologia empregada para aferição dos valores, a ser comprovada *“com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor específico do projeto”*.

2.16 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração, querendo dar seguimento ao certame, adote as medidas corretivas pertinentes para dar cumprimento à lei e a esta decisão, em especial:

- a) estabelecer a vigência da garantia de proposta de acordo com o período de validade da oferta;
- b) permitir a participação de empresas reunidas em consórcio sem qualquer limitação ou justificar tecnicamente a delimitação, se mantida;
- c) aprimorar os Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeiro, disponibilizando todas as informações pertinentes;
- d) informar os valores de cobertura das apólices de seguro;
- e) corrigir a discrepância de valores entre o EVTE e a Minuta do Contrato;
- f) reavaliar o valor da tarifa média de água adotado como parâmetro no EVTE;
- g) indicar o método adotado para o cálculo da depreciação e amortização;
- h) adequar a base de cálculo para a prova do patrimônio líquido mínimo e da garantia de proposta; e
- i) esclarecer a metodologia empregada para aferição dos valores de investimentos pelo período da concessão.

¹⁹ O Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: (...) § 4º Os estudos de engenharia para a definição do valor do investimento da PPP deverão ter nível de detalhamento de anteprojeto, **e o valor dos investimentos para definição do preço de referência para a licitação** será calculado com base em valores de mercado considerando o custo global de obras semelhantes no Brasil ou no exterior ou **com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento sintético**, elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica. (grifei)

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO